

1500817-36.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... teria trazido consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha, com peso líquido de 78,03 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que "na data dos fatos, policiais militares receberam informação, via COPOM, de que o denunciado estaria praticando o tráfico de drogas na rua 24 em cruzamento com a rua C, bairro Paranoá, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500817-36.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500817-36.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wuolen Alvarenga Ventola

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. WUOLEN ALVARENGA VENTOLA, qualificado nos autos a fls. 11, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 30

de dezembro de 2021, por volta de 20h27min, na Rua 20 nº 1.224, Bairro Paranoá, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha, com peso líquido de 78,03 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que “na data dos fatos, policiais militares receberam informação, via COPOM, de que o denunciado estaria praticando o tráfico de drogas na rua 24 em cruzamento com a rua C, bairro Paranoá, nesta cidade e comarca. Nesse contexto, os policiais foram até o local, ocasião em que encontraram o denunciado trafegando em uma bicicleta.

Após visualizar os militares, WUOLEN tentou empreender fuga, sendo ele acompanhado pela guarnição até a rua 20, defronte ao nº 1224, oportunidade em que foi detido. Realizada busca pessoal, com ele foi encontrada a quantia de R\$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais) em notas fracionadas em diversas cédulas. WUOLEN ainda tentou dispensar durante a fuga 1 (um) 'tijolinho' de maconha.”.

A denúncia de fls. 110/111 foi recebida em 24 de janeiro de 2021 (fls. 113), sendo o Réu citado (fls. 128), apresentando defesa preliminar em fls. 136/142, rejeitada em fls. 151/155. Durante a instrução foi colhida prova testemunhal e interrogado o Réu (fls. 208/214).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 206/207).

A douta Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação sustentando a ausência de prova da prática do tráfico, uma vez usuário de entorpecente, requerendo sua absolvição e, subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 215/217).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/04), boletim de ocorrência de fls. 06/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08, auto de constatação de fls. 21/23, na guia de depósito judicial (fls. 102), pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 124/126, além da prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra o Réu que em Juízo negou o teor da denúncia, sustentando que no dia dos fatos descia a rua de bicicleta, carregando a quantia de R\$ 1.075,00 entregue por seu tio, que havia recebido abono salarial e se destinada a adquirir garrafas de uísque, porque pretendia abrir uma adega, mas naquele momento os policiais pararam com a viatura ao seu lado e o abordaram, dizendo que ele tinha perdido, resistindo em ser algemado, mas foi colocado no veículo e levado até a delegacia de Guaíra e, em seguida, a de Barretos, alegando que a droga não foi apresentada e somente quando já estava preso ficou sabendo que seria pelo tráfico. Ademais, faz uso de maconha e é ajudante de pedreiro (fls. 208/210).

Sua versão não se sustenta e deveria ser por ele comprovada, notadamente a alegação de que o dinheiro seria de seu tio, porque apesar do extrato, praticamente ilegível, apresentado em fls. 217, não houve sua confirmação em Juízo, notadamente pela oitiva do tio do Acusado, caindo por terra a alegação, até porque o valor mencionado que teria sido sacado (R\$ 1.500,00), sequer é compatível com o que foi apreendido (fls. 102), lembrando que se tratava de ônus cabível à Defesa, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O policial militar Almeani, em fls. 208/210, relatou que foi informado sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado por algumas pessoas na Rua 24, sendo que durante o deslocamento da viatura até lá se depararam com o Réu, conhecido dos meios policiais e quando foram abordá-lo ele tentou fugir de bicicleta, jogando grande quantidade de dinheiro no chão para o pessoal pegar e ele conseguir se desvencilhar dos militares. Contudo, conseguiram pegá-lo, ele resistiu, as pessoas se apoderaram de parte do dinheiro e durante a revista encontraram nas vestes do Acusado a porção de maconha. Ressaltou, ainda, ser o Réu conhecido dos meios policiais pela traficância, sendo um dos donos da biqueira em que ele estava e conseguiram recuperar de parte do dinheiro, dizendo, ao final, que ele não aparentava estar sob efeito de drogas.

Note-se que nada há nos autos a evidenciar que a testemunha visasse imputar falsamente ao Réu uma conduta criminosa.

O comportamento do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia trazia consigo substância entorpecente para fins de traficância, uma vez que ele é conhecido dos meios policiais pelo tráfico – tanto que ostenta duas condenações transitadas em julgado por este crime, conforme se verá na fase de dosimetria da pena, assim como ele tentou fugir ao avistar a viatura, trazer consigo razoável quantia em dinheiro sem origem lícita e, ademais, carregava considerável quantidade de droga em um tablete, dando mostra clara de que serviria ao tráfico, porque é certo que um usuário de droga adquire pequenas porções fracionadas, não um tijolo de maconha. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006, inviabilizando por completo o pedido de desclassificação formulado pela douta Defesa para o tipo do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Dessa forma, considerando o quadro posto, certa a procedência da ação penal. Oportuno salientar não ser necessária prova do ato do comércio, em especial porque o tipo do artigo 33 da Lei de regência é considerado misto alternativo e a venda não é a única conduta nele descrita que possui, dentre outras, a de trazer consigo, como na hipótese em análise, de forma que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policial, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo por que não pode ser descartado. A condição funcional não o torna suspeito, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão: “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos. Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram” (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado é reincidente, demonstrando ter personalidade persistente na prática de condutas antissociais. Contudo, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal para não provocar um bis in idem com a agravante da reincidência. Sendo assim, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, onde não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, a pena-base ser fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor à míngua de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/3 (um terço) em razão da dupla reincidência específica (fls. 30, autos nº 0000343-89.2016.8.26.0210 e fls. 30/31, autos nº 0001921-24.2015.8.26.0210), denotando fazer do tráfico seu meio de subsistência, ao detrimento da vida e da saúde de incontáveis usuários de droga, exigindo, com isso, maior vigor estatual na imposição da pena, atingindo, dessa forma, o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, que a torno definitiva.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele conhecido pela traficância naquele ponto de venda, tanto que anteriormente já condenado pelo mesmo crime, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o

tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminoso, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destruir outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Crim., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos objetivo e subjetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito (sendo que o Réu não é possuidor de nenhum destes predicados, tanto que não comprovou a alegada ocupação lícita) servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto

de acordo do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se ser relacionado à venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu e depositados em fls. 102, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o Réu WUOLEN ALVARENGA VENTOLA, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em seu piso legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro apreendido com ele, depositado em fls. 102, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário apreendido, com depósito em fls. 102, em benefício da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que preso em flagrante fosse posto em liberdade depois de condenado.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA